

Riassunti

"Sul dovere giuridico"

1.FILOSOFIA E DIRITTO

La filosofia è in sostanza lo studio del tutto, similmente la filosofia del diritto si occupa del dovere giuridico; ha dinanzi il tutto. La filosofia del diritto è la scienza del dovere giuridico.

Si possono distinguere doveri secondo la forza del dovere stesso (ad intra) e doveri secondo l'oggetto (ad extra). Sapere se vi sono doveri necessari o soltanto possibili implica esplorare la forza del dovere. Distinguere tra doveri di condotta e doveri di struttura o, doveri di doveri. Il dovere giuridico, inteso come obbligo giuridico, è uno dei sensi della norma giuridica; il permesso giuridico, che è l'altro senso fondamentale, è riconducibile al dovere giuridico. Il permesso quindi implica il dovere giuridico e, dove vi è un obbligo, vi è pure una pretesa e viceversa. Il diritto è la totalità delle norme che esistono in un ordinamento. L'ordinamento è l'insieme delle norma valide.

Necessaria per l'esistenza stessa dell'ordinamento è la norma fondamentale di Kelsen: "Ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace." Essa è un esempio di dovere giuridico necessario e, senza questa norma, non sarebbe pensabile un ordinamento. Affermando che sono norme valide solo quelle dell'ordinamento, si determina anche quali norme non sono valide.

Una classificazione di norme, secondo la forza del dovere, è quella tra norme necessarie e norme non necessarie, tra doveri giuridici necessari e doveri giuridici non necessari.

Oltre che secondo la forza del dovere, le norme si distinguono anche secondo l'oggetto. Una classificazione di norme secondo l'oggetto è quella tra norme primarie(primary rules) e norme secondarie(secondary rules). Questa distinzione è stata effettuata dall'inglese Hart.

Norme primarie sono le norme di condotta. Esse istituiscono rapporti giuridici, stabilendo ciò che si deve o non si deve fare.

Norme secondarie sono quelle di struttura, ossia norme che creano ed organizzano un ordinamento giuridico. Le norme di struttura sono norme su norme; vertono non su comportamenti ma su altre norme, o, esprimono doveri su doveri.

Dalla relazione tra le norme primarie e le norme secondarie si può operare una distinzione tra la posizione presa dal positivismo giuridico e quella presa dal giusnaturalismo.

Nella prospettiva del **positivismo giuridico**, le norme di struttura sono condizione sia necessaria, sia sufficiente di validità delle altre norme. Ogni dovere giuridico dipende da atti specifici di produzione, atti qualificati dalle corrispondenti norme di struttura. Non è però sufficiente un requisito soltanto formale di validità perché le norme siano dotate di una forza veramente giuridica. Non basta riferirsi ad un legislatore perché le leggi abbiano un'esistenza giuridicamente valida. Non sono sufficienti norme di struttura.

Secondo il **giusnaturalismo** vi sono doveri in sé sussistenti che non hanno bisogno di atti specifici di produzione e questo determina la perdita di importanza delle norme di struttura. Al contrario, l'esistenza di doveri necessari, poiché in sé evidenti, esprime la necessità di un legislatore, di modo che occorrerà sempre che vi siano norme di struttura.

Vi sono doveri necessari, ma non sono necessarie le norme corrispondenti. Ad esempio: se v'è un testamento olografo è necessario che sia un atto sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Non è necessario, però, che un determinato ordinamento giuridico fissi la rilevanza di un testamento olografo poiché esso è già rilevante di per sé.

La filosofia è metafisica in senso kantiano, è cioè scienza dell'universale. Per questa ragione la filosofia si occupa non di tutti i tipi di dovere, ma del dovere giuridico sotto la specie dell'universale. Tratta il particolare perché interessa solo la possibilità dei singoli fenomeni, e quindi, studiare la possibilità dei fenomeni è sapere quali fenomeni sono universali o necessari, e quali no.

All'interno del diritto non vi sono quindi solo doveri semplici ma, vi sono anche doveri necessari, senza i quali il diritto stesso cesserebbe di essere quello che è. Senza questi doveri infatti, vi sarebbe soltanto contraddizione. Al diritto serve in altre parole una **giustificazione** di fronte all'uomo. Una norma quanto più è giustificata tanto più è efficace. Una norma affatto giustificata per i destinatari non ha sicuramente efficacia, e finisce per non essere più una norma. Ad esempio: poniamo che la legge sia la seguente: "tutti i membri del Parlamento sono da un momento in poi liberati da ogni limitazione da parte di qualsiasi legge". È evidente che una legge del genere sarebbe sì conoscibile, ma non riconoscibile come legge. Considerata come legge valida, vanificherebbe tutto l'ordinamento.

Non vi sono solo norme giuridiche. Vi sono anche norme diverse da quelle giuridiche; ad esempio: **le norme morali**. Esse sono di per sé norme, ma non costituiscono norme giuridiche. Anche una norma totalmente immorale non è una norma giuridica. Norme immorali sono le **norme delinquenziali**. Un esempio è la richiesta del tutto immorale "O la borsa o la vita". Questa richiesta esprime a suo modo un dovere ma non può essere considerata un dovere giuridico. Alle norme delinquenziali manca la ragione. Una differenza specifica dalle norme giuridiche sta proprio nel fatto di poter essere giustificate per ogni possibile destinatario. Un giurista che opera con il diritto

non può limitarsi a dire cosa si deve e cosa non si deve fare ma, egli deve offrire una ragione rappresentabile da tutti o, per meglio dire, **una ragione universale**.

2.POLITICA E DIRITTO

La filosofia è scienza dell'universale, la politica del particolare. La prima è scienza della possibilità dei fenomeni, la seconda dei fenomeni solo possibili. La politica ha a che fare con la filosofia perché ne è n suo oggetto essendo la politica un momento necessario del processo giuridico. Non v'è diritto senza politica.

Il processo giuridico: l'ordinamento giuridico è un sistema dinamico. L'ordinamento è composto da una concatenazione infinita e sempre nuova di atti giuridici, a cui è collegato un continuo processo di creazione giuridica. Si distinguono quindi: atti che creano diritto oltre il diritto che si ha (**atti di legislazione**) e atti che creano diritto dal diritto che si ha (**atti di giurisdizione**). Vi sono quindi atti che creano diritto o aggiungendo nuove norme all'ordinamento, oppure ricavando nuove norme da quelle già esistenti nell'ordinamento. È necessaria però un'attività continua di produzione di norme perché se non fosse così, l'ordinamento perderebbe la sua effettività. Esempio Repubblica di Weimar.

I procedimenti della logica giuridica:

Il giurista, che applichi i due principali procedimenti della logica giuridica, cioè **dell'analogia** e **dell'argomento a contrario**, intende rispondere alle lacune della legge. Il compito del giurista è di integrare il diritto, a partire sempre dal diritto che c'è, e dimostrare il significato delle norme che già ci sono, e non di creare una nuova norma.

Ad esempio: si immagini la norma "è vietato l'ingresso ai cani" davanti ad una sala d'attesa in una stazione ferroviaria. La norma sembra impedire l'ingresso solo ai cani senza distinzione di razza, taglia, ecc. si avvicina un uomo con un orso. **Il senso comune** ci dice che il divieto non vale solo per i cani ma anche per gli orsi. Adesso però si avvicina un poliziotto con il suo cane. Cosa fare? Il senso comune ci dice che il divieto vale per tutti i cani ma non per quello che accompagna il poliziotto.

Queste due soluzioni sono a fondamento dei due procedimenti della logica giuridica. Secondo il procedimento per analogia, dalla norma che prevede un certo caso (N1) si ottiene, mediante un'interpretazione relativa allo scopo della norma stessa, la norma che prevede lo stesso divieto per quelli animali simili al cane nell'arrecare un certo disturbo (NN). Da NN è prodotta una nuova norma che vieta l'ingresso agli orsi (N2).

N1 → NN → N2

Secondo il procedimento dell'argomento a contrario, da N1 si giunge, sempre mediante un'interpretazione relativa allo scopo della norma di partenza, alla norma che esclude tale divieto per quelli animali che invece procurano beneficio nella sala d'attesa (NN). Da questa norma è prodotta la norma N2 che non vieta, anzi dà il permesso al cane poliziotto di entrare.

N1 → NN → N2

Il presupposto che sottintende l'applicazione dei giuristi di questi due procedimenti è che l'ordinamento non è completo. Vi sono casi che l'ordinamento non ha previsto. L'ordinamento non dispone subito di tutte le norme di cui ha bisogno. Si pensi all'art.1 del Codice Penale("Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge"). Questo articolo sembra introdurre per ogni caso non previsto, una previsione indiretta di permissione. In questo modo l'ordinamento penale opererebbe un automatico completamento rispetto ad ogni caso non previsto. Si pensi invece all'art.12 del Codice Civile ("In caso di lacuna si deve avere riguardo alle disposizioni che regolano **casi simili o materie analoghe**"). Per il diritto civile così, non v'è il principio che se manchi una disposizione, e si abbia un caso non previsto, quest'ultimo sia trattato con una precisa modalità deontica (il permesso). Il diritto civile a differenza di quello penale ammette l'esistenza di lacune, ed è perciò incompleto. È inevitabile quindi, per il diritto civile, creare nuove norme da quelle che si hanno. Non vi sono infatti sentenze in campo civile che si concludono invocando una norma di permissione per i casi non previsti.

Per applicare i procedimenti della logica giuridica non ci si può fermare ad **un'interpretazione letterale** delle norme, che si fermi al solo significato delle parole. L'interpretazione che si rende inevitabile per quei procedimenti è quella di una interessenjurisprudenz, di una **giurisprudenza degli interessi**: ciò che si deve stabilire è lo scopo delle norme di partenza nei due procedimenti. Infatti l'interpretazione letterale di N1 non permetterebbe di arrivare ad N2. Se si interpreta alla lettera la norma, solo i cani non possono entrare mentre gli orsi si. È necessaria un'interpretazione, dunque, secondo lo scopo o gli interessi, la cosiddetta **interpretazione fondamentale.** La stessa interpretazione letterale impedirebbe il passaggio da N1 a N2 quando si usa l'argomento a contrario, perché in tal caso ogni animale che sia un cane non dovrebbe entrare, compreso il cane del poliziotto. Stando all'ordinamento giuridico italiano però, si deve applicare la legge badando al significato letterale. L'**inevitabilità** dei procedimenti della logica giuridica, rende inefficiente l'interpretazione letterale. Non vi è però un criterio oggettivo per adottare un tipo di interpretazione che un'altra.

Tutte le volte che è possibile applicare la prima regola, è di per sé possibile dal punto di vista logico, applicare anche la seconda regola. L'analogia implica la differenza; e quindi, il procedimento per analogia implica sempre l'argomento a contrario.

Importante anche la **decisione giuridica.** Essa è inevitabile in virtù o di un obbligo (**Sollen**), oppure di una necessità (**Müssen**). La decisione giuridica è innanzitutto al termine di un obbligo (Sollen). In tutte le codificazioni moderne il Giudice ha l'obbligo di decidere in ogni caso. Il Codice di Napoleone, esclude espressamente all'art.4 la facoltà del Giudice di denegare giustizia, rendendo penalmente responsabile il Giudice che rinunci ad emettere una sentenza.

La decisione giuridica è al termine, se non di un obbligo, sicuramente di una necessità (Müssen). È necessità materiale che il Giudice giunga ad un giudizio, giacché l'eventuale astensione dal giudizio del Giudice, è di per sé già un giudizio.

3.DIRITTO E PAROLA

Una filosofia del dovere giuridico è anche scienza del linguaggio. Il diritto, è infatti parola. Il diritto anche se non è linguaggio, ne ha certamente uno, cioè quello degli infiniti atti del processo

giuridico: gli atti di linguaggio (**Speech act**). Vi è poi una distinzione dei verbi utilizzati per l'esecuzione linguistica di atti giuridici effettuata dal filosofo Austin:

- **Verbi verdittivi**: quando il soggetto esprime una sentenza (assolvere, condannare);
- **Verbi espositivi**: quando il soggetto non giudica una cosa, ma prende una posizione rispetto al mondo (dichiarare, affermare).
- **Verbi esercitivi**: sono quelli mediante i quali il soggetto non giudica ma esercita il potere, verbi quindi utilizzati dal legislatore (disporre, decretare).
- **Verbi commissivi**: corrispondono alla coerenza del soggetto a compiere determinati atti in futuro (promettere, giurare).
- **Verbi comportativi**: esprimono la dimensione sociale della vita del soggetto (salutare).

Il diritto non ha senso senza linguaggio perché esso ha certamente a che fare con il diritto. Vi è una relazione anancastica (necessaria) tra norma e parola. Esempio: il testamento olografo è un testamento scritto di proprio pugno dal testatore. Quando si parla di testamento olografo si fa automaticamente riferimento alla norma che lo regola. Il linguaggio invece, non implica per forza l'esistenza di una norma. Esempio: "è vietato mangiare le fave" è un enunciato normativo, ma non è una norma valida nel nostro ordinamento.

Il linguaggio del diritto comporta essenzialmente il senso di enunciazioni performative. Questo concetto è stato adoperato dal filosofo Austin con la sua teoria: il soggetto mediante un enunciato performativo causa un cambiamento in colui che subisce l'azione. Il linguaggio performativo consiste negli Speech act del processo giuridico. Bisogna che l'enunciato performativo sia costruito alla prima persona singolare del presente indicativo. E queste sono le condizioni necessarie per la performatività del linguaggio giuridico.

Il linguaggio performativo è il linguaggio attraverso cui il soggetto fa ciò che dice; il soggetto con le enunciazioni performative non esegue un'azione qualsiasi ma, quella che sta dicendo. Con "ti prometto", si ha una promessa che nasce con le parole, non prima delle parole stesse ma, con la frase "ti prometto". La stessa cosa succede se dico "mangio la mela". Questo vale anche per il linguaggio giuridico con l'enunciazione tipica "si dispone che Op".

La parola è sempre performativa. Anche le enunciazioni di enunciati cognitivi presuppongono sempre enunciazioni con un verbo performativo. Dire "mangio la mela" presuppone implicitamente un'enunciazione del tipo "affermo che mangio la mela". Quest'ultima enunciazione evidenzia il verbo performativo affermare. E la parola è sempre performativa perché è l'esecuzione dei tanti atteggiamenti che il soggetto assume di fronte al mondo.

Il linguaggio giuridico individua due tipi di enunciazioni performative. Da una parte vi sono enunciazioni che sono un discorso costitutivo di **status** deontici (obblighi, divieti, permessi), dall'altra vi sono enunciazioni che sono un discorso cognitivo di **status** deontici. Nel primo caso si ha una **thesis** e nel secondo una **rhesis**. Esempi: il legislatore dice: "si dispone che Op". vi è un verbo performativo e un enunciato innestato "è obbligatorio P". il giurista dice: "affermo che Op". anche qui vi è un verbo performativo e lo stesso enunciato innestato. È evidente però che i due tipi di enunciazione sono differenti tra loro. La prima la si potrebbe etichettare come **enunciazione performativa thetica** , la seconda come **enunciazione performativa rhetica**.

Le enunciazioni performative thetiche pongono deonticamente la deonticità dell'enunciato innestato. Grazie alle enunciazioni del legislatore si costituisce lo status deontico (obbligo, divieto) che viene descritto dall'enunciato innestato. Dicendo "si dispone che Op" nasce l'obbligo di P. per questo motivo, le enunciazioni performative thetiche pongono la verità dell'enunciato innestato. L'enunciato "è obbligatorio P" è sempre vero, quando è innestato in un'enunciazione performativa thetica.

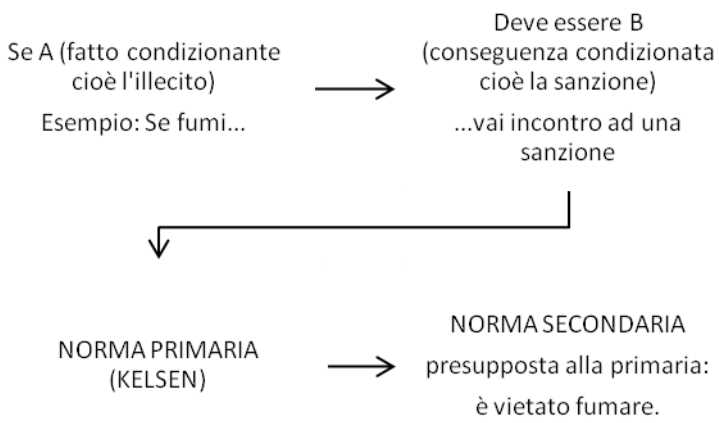
Le enunciazioni performative rhetiche pongono cognitivamente la deonticità dell'enunciato deontico innestato. Quando il giurista dice "affermo che Op", non è in virtù di questo enunciato che nasce l'obbligo di P. chi afferma ciò pone una cognizione sull'esistenza di un certo obbligo. Si fa quindi un'affermazione sull'esistenza di uno status deontico ma, non si costituisce uno status deontico. Le enunciazioni performative rhetiche non sono in grado di porre la verità dell'enunciato innestato.

La performatività chiama però in causa anche un altro fenomeno, quello della **costitutività del linguaggio giuridico**.

Le norme costitutive sono norme che eseguono ciò che dicono nel momento stesso in cui sono poste, sono norme senza adempimento, perché identificano lo status di un soggetto. Sono norme costitutive le norme abrogative, le quali abrogano se stesse. È una norma costitutiva anche la norma che dispone una nuova determinazione in un ordinamento giuridico, perché essa, come quelle abrogative, è eseguita nel momento stesso in cui è posta. Vi sono poi le **norme prescrittive**, che non eseguono se stesse in forza solo della loro validità; sono la conseguenza delle norme costitutive e si eseguono tramite i comportamenti dei destinatari.

Nell'ordinamento giuridico si trovano sia norme prescrittive (Esempio: art.144 del Codice Civile "la moglie è obbligata a seguire il marito ovunque egli creda di fissare la sua residenza"), sia norme costitutive (Esempio: art.144 del Codice Civile "il marito è il capo della famiglia").

Per il fatto che le norme prescrittive, a differenza delle norme costitutive, per la loro esecuzione, hanno bisogno di certi atti di adempimento, da questo punto di vista non sarebbe vera la tesi di Kelsen, secondo cui il diritto è un insieme di norme prescrittive-sanzionatorie. Le **norme primarie** sono per Kelsen le norme che imputano ad un fatto condizionante (**l'illecito**) una conseguenza condizionata (**la sanzione**). Lo schema delle norme primarie è quindi :



A differenza della teoria di Kelsen, secondo la teoria della costitutività, non vi sono solo norme prescrittive perché non tutte le norme sono munite di sanzione. Non sono munite di sanzione le norme che si eseguono senza bisogno di adempimento. Perciò il linguaggio giuridico è sia costitutivo, sia prescrittivo.

Comunque sembra prevalere il senso prescrittivo del diritto visto che ciò è quello che emerge osservando l'ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico sta soprattutto per prescrivere comportamenti. Le norme costitutive sono in funzione delle prescrittive e non viceversa. Esempio è l'art.70 della Costituzione, che è una norma costitutiva: "la funzione legislativa è esercitata dalle due Camere". Questa norma non avrebbe senso senza le infinite norme prescrittive promulgate dalle due camere nell'esercizio della loro funzione legislativa.

Anche norme costitutive però possono avere un senso prescrittivo ed essere tradotte nello schema di Kelsen. Si pensi infatti ad una norma abrogativa. Ciò che prima era permesso ora è vietato. È bene se i destinatari si comportassero come se certe norme non fossero state abrogate, quindi come se ci fosse ancora un permesso anziché il divieto, si determinerebbe una situazione di illecito, con tutte le conseguenze anche in termini di sanzione.

Le norme costitutive infine, anche se non sono prescrittive in un senso diretto ed immediato, lo sono almeno indirettamente. Basti pensare alle regole di un gioco. È una regola costitutiva la regola che definisce il Re nel gioco degli scacchi e, tale regola, fissa tutte le mosse che il re può fare nel gioco. Questa regola non stabilisce però quali mosse il giocatore deve fare, però delimita lo stesso un ambito di mosse entro cui il giocatore deve muoversi. La regola non dice quali mosse uno deve fare, ma determina quali mosse può fare, e in questo senso le norme costitutive hanno un necessario carattere di prescrittività.

4.DIRITTO E LOGICA

Non v'è scienza dei doveri giuridici, senza anche una logica della validità delle norme.

Si può dire delle norme che sono vere?

Sembrerebbe di no: delle norme non affermiamo che sono vere o false, semmai che sono valide o invalide. Guardando alla performatività del linguaggio giuridico. Le norme sono, sotto l'aspetto dei fenomeni del linguaggio, o enunciati di enunciazioni performative, o enunciati innestati in enunciazioni performative.

Si può allora predicare la verità di enunciati di enunciazioni performative?

Esaminiamo una tesi di Amedeo Conte: è possibile predicare la verità sia di enunciati che traducono semplicemente un'enunciazione performativa ("si dispone che Op"), sia di enunciati innestati in enunciazioni performative ("è obbligatorio P").

Degli enunciati in enunciazioni performative si deve affermare che sono sempre veri. Essi si distinguono per un tratto davvero peculiare: quello dell'**autoreferenzialità**. Dicendo "si dispone che Op" nasce in realtà una disposizione. Pertanto, l'enunciato finisce per descrivere o riferirsi a se stesso e dunque, essere sempre vero. Esso, in altre parole, si autoverifica. Per questa ragione enunciati di enunciazioni performative sono sempre veri.

Un enunciato performativo falso è un **falso performativo**. La verità di un enunciato performativo viene meno se manca una condizione necessaria per la validità dell'atto stesso (esempio del battesimo). Non ci troviamo di fronte ad un enunciato performativo falso ma, ad un falso performativo. Allo stesso modo, non sono parole che hanno un senso performativo quelle di un'eventuale promessa di cosa passata.

Che dire degli enunciati innestati in enunciazioni performative?

La risposta segue la distinzione già fatta in precedenza tra "thesis" e "rhesis". Le enunciazioni del legislatore sono enunciazioni performative thetiche. Grazie all'enunciazione del tipo "si dispone che Op" il legislatore costituisce un obbligo; l'obbligo appunto di P. Tale obbligo è anche il tema dell'enunciato normativo "è obbligatorio p", enunciato innestato nell'enunciazione performativa: "si dispone che Op". Il nesso necessario tra la costituzione dell'obbligo di P e l'enunciazione performativa "si dispone che Op" determina il risultato secondo il quale l'enunciato normativo "è obbligatorio P", non soltanto si può dire vero, ma è anche per forza di cose vero. Questo enunciato collegato all'enunciazione del legislatore, descrive uno stato di cose che risale alla stessa enunciazione del legislatore. Tutte le volte che il legislatore pronuncia le parole "si dispone che Op", ecco che nasce l'obbligo di P. L'enunciato "è obbligatorio P" si autoverifica.

In tal senso, secondo Amedeo Conte, le enunciazioni performative pongono la verità dell'enunciato innestato. La stessa cosa non succede con le enunciazioni performative rhetiche. Quando il giurista dice quali dono gli obblighi o i divieti vigenti si mette nelle condizioni di fare un'affermazione eventualmente falsa. Dicendo: "affermo che Op", non per questo nasce l'obbligo di P. L'enunciato "è obbligatorio P", innestato questa volta nell'enunciazione performativa del giurista che descrive un certo ordinamento, può essere un enunciato falso.

Poniamo tre osservazioni:

Gli enunciati, in enunciazioni performative, sono veri perché si auto verificano. Tali enunciati si auto verificano poiché essi sono il fatto stesso che descrivono. Il fatto non ha luogo realmente senza l'enunciazione performativa di quell'enunciato che ha per tema lo stesso fatto; basta che vi sia una tale enunciazione perché il fatto vi sia.

Dei fatti non si dice che sono veri o falsi, ma che vi sono oppure no. Il **senso ontico** di verità di un fatto o di un oggetto sta ad indicarne l'esistenza. **Verità ontica** e **verità semantica** sono tra loro prive di connessione. Esempio: si pensi ad una banconota che è un oggetto che sta per un'obbligazione di pagamento; una banconota americano nello specifico. Sulla banconota sono stampati due enunciati:

1) "Noi confidiamo in dio";
2) "Questa banconota è mezzo legale di pagamento per debiti, pubblici o privati".

Il valore di verità di enunciati (**verità semantica**) sulla banconota non è di per sé condizionato dall'eventuale falsità ontica della banconota stessa. L'eventuale falsità ontica della banconota non è condizione sufficiente affinché l'enunciato (1) "noi confidiamo in dio" sia semanticamente falso. Al contrario dell'altro enunciato (2) "questa banconota è mezzo legale di pagamento per debiti, pubblici o privati". In questo caso l'eventuale falsità della banconota è sufficiente affinché

quell'enunciato sia semanticamente falso. Le condizioni per cui verità semantica e verità ontica siano tra loro collegate sono allora:

- Che l'enunciato faccia riferimento all'oggetto stesso su cui esso ricorre(quindi la banconota fa riferimento a se stessa dicendo "questa banconota").
- Che l'enunciato predichi la validità dell'oggetto (ciò che la banconota predica di se stessa concerne il suo valore dicendo "è mezzo legale").

Verità ontica e verità semantica non sono, dunque, la stessa cosa. Nel linguaggio giuridico il senso ontico di verità è la validità giuridica.

L'altro quesito è questo: ha senso predicare la verità quando non si può se non predicare la verità?

Gli enunciati performativi sono sempre veri. Enunciati performativi falsi sono dei falsi performativi. Ciò ha senso anche per gli enunciati di cui si predichi una verità universale e necessaria. L'enunciato, ad esempio: "ogni corpo è esteso" è un enunciato di cui si predica una verità, e una verità universale e necessaria. L'enunciato si dice vero perché descrive uno stato di cose. Il fatto di descrivere uno stato di cose è il requisito che un enunciato deve avere per far parte dell'insieme degli enunciati di cui ha senso affermare la verità o la falsità. L'enunciato "ogni corpo è esteso" è un enunciato necessariamente vero, ma ha la stessa grammatica di un enunciato che può essere falso. Gli enunciati performativi possono essere solo veri. Essi più che descrivere, creano uno stato di cose.

Ammesso pure che si ossa predicare una verità in senso logico degli enunciati innestati in enunciazioni performative, tale predicato sembra alla fine lo stesso irrilevante per il processo giuridico. Basti pensare alle conseguenze del sillogismo giuridico. Il sillogismo potrebbe essere il seguente:

I) Tutti i ladri devono essere puniti; (Premessa maggiore)
II) Tizio è un ladro; (Premessa minore)
III) Tizio deve essere punito; (Conclusione in senso logico - sentenza di condanna)
IV) Tizio non deve essere punito; (Conclusione in senso ontico - sentenza di assoluzione)

La verità sarebbe il predicato sia delle due premesse, sia della conclusione. In senso logico, una conclusione diversa (IV) sarebbe, infatti, contraddittoria. La verità è predicato irrilevante nel processo giuridico, a meno che non sia intesa in senso non più logico, bensì ontico. La conclusione "Tizio non deve essere punito" è in sé vera e non contraddittoria, giacché non deriva dalla verità delle due premesse ma dalle condizioni di validità di un atto come la sentenza del Giudice nel processo.

Questo risultato permette di discutere ancora due tesi:

La prima tesi

La funzione pragmatica e il significato semantico di un enunciato sono indipendenti tra loro.

La funzione pragmatica è l'atto che si compie usando quella proposizione: un comando, un ipotesi.(I).

Il significato semantico è la grammatica della proposizione.

Il discorso cognitivo si differenzia da quello normativo solo sotto il profilo pragmatico. Secondo questa tesi, le regole della logica sono regole di trasformazione delle proposizioni, fatta astrazione dalla funzione pragmatica. È una condizione sufficiente di validità normativa la logica di derivare una norma da un'altra.

(I)Tutti i ladri devono essere puniti → (II) Tizio è un ladro → (III)Tizio deve essere punito.

La seconda tesi

Secondo il filosofo del linguaggio normativo Kalinowski fa coincidere la validità delle norme con la corrispondenza di essi a ciò che egli chiama la "realité déontique", ossia uno status deontico che non è costituito, bensì precostituito all'enunciazione degli enunciati deontici stessi. Da questo punto di vista la validità di una norma propriamente la verità, in senso logico, di essa. Una norma valida è un enunciato che descrive un reale status deontico esistente.

Le due tesi che sono appena state esposte hanno un tratto comune problematico, ed è quello di fare astrazione dal carattere normativo delle norme senza tener conto della funzione pragmatica delle proposizioni normative.

Il discorso cognitivo si differenzia in realtà da quello normativo sotto l'aspetto pragmatico. Il linguaggio delle norme non è mai semplicemente descrittivo. Esso è, semmai, dichiarativo. Il linguaggio delle norme opera quindi, un consolidamento di status deontici in sé sussistenti.

Vi è una relazione necessaria tra mezzi e fini. Occorre, tuttavia, la norma a far sì che la regola che identifica tale relazione necessaria sia valida in un determinato ordinamento giuridico.

Qual è la logica del linguaggio giuridico?

Non una logica della verità, ma della validità. Distingueremo rispettivamente due ambiti principali della validità giuridica:

- La validità pragmatica, che dice dell'esistenza di atti;
- La validità sintattica, che dice dell'esistenza di norme in un ordinamento.

5.DOVERI PRAGMATICI

La **validità pragmatica** è lo studio delle condizioni di validità di atti. Si tratta della validità di una specie di atti linguistici(speech acts): gli atti giuridici.

La validità pragmatica si può dividere in:

- **Validità pragmatica prima o praxeologica**;
- **Validità pragmatica seconda o praxeonomica**.

La validità praxeologica è scienza delle condizioni che risalgono all'idea (eidos) stessa dell'atto di cui si predica la validità.

La validità praxeonomica è, invece, scienza delle condizioni che risalgono a norme (nomoi) che, *ab extra* rispetto alla pure idea di un atto, pongono condizioni di validità.

La validità praxeologica

Essa esprime doveri necessari e universali, senza dei quali vi sarebbe l'impossibilità dell'atto o la sua trasformazione. Ad esempio: la condizione per cui una promessa non può essere una promessa di cosa passata è tipicamente una condizione praxeologica di validità della promessa. Senza questo dovere una promessa sarebbe priva di senso e, dunque, impossibile. La promessa è un modo di sottoporsi ad un'obbligazione. Ci si può obbligare verso ciò che ha da essere, e non verso cosa che già è o è stata. Non ha senso dire: "prometto che ti sono stato fedele"; semmai, ha senso dire: "prometto di esserti fedele". Sotto la forma apparente di una promessa rivolta al passato è eventualmente possibile fare solo delle assicurazioni. Nel caso si dica: "prometto di aver fatto tutto il possibile", in realtà non si esegue una promessa, ma si esprime solo un'assicurazione. Una promessa di cosa passata è un paradosso pragmatico così come lo sarebbe una promessa d'inadempimento della stessa promessa: "prometto di non mantenere la presente promessa". Una promessa è sempre promessa d'adempimento poiché è un modo di obbligarsi.

È un esempio giuridico di validità praxeologica la condizione per cui un atto di abrogazione è tale se di norma valida e non di norma invalida.

Nella teoria generale del negozio giuridico di Emilio Betti sono condizioni di validità praxeologica gli "***essentialia negotii***". Gli "*essentialia negotii*" sono "cause essenziali del negozio, elementi necessari a costruire un negozio di quel determinato tipo che si considera, cioè tali che senza di essi il negozio di quel tipo non potrebbe sussistere". Se si pensa, ad esempio, ad un negozio come la compravendita, si suole affermare che sono elementi essenziali: le parti, il consenso, l'oggetto.

La validità praxeologica esprime condizioni che hanno la stessa natura (la natura di condizioni necessarie ed universali), ma non sono della stessa specie. Vi sono almeno due tipi di condizioni:

- condizioni che risalgono alla **struttura** essenziale di atti;
- condizioni che risalgono alla **funzione** essenziale di atti.

Struttura e funzione non sono però la stessa cosa.

Occorre spiegare la differenza tra struttura e funzione. A dimostrare la differenza tra struttura e funzione è la logica dei segni e dei significati. Il segno sta per la struttura di un'entità linguistica, mentre il significato sta per la funzione o l'uso di un'entità linguistica.

Uno stesso uso o significato può avere segni differenti; così pure uno stesso segno può avere usi e significati differenti. Se significato e segno fossero la stessa ed identica cosa non vi sarebbe alcuna variazione tra segno e significato.

Lo stesso uso o significato può avere segni differenti. Si prendano ad esempio "x" e "y". Una doppia "x" indica un'affermazione, mentre una doppia "y" una negazione rafforzata. Ora tutte le volte in cui i due segni non sono ripetuti hanno il significato di una negazione semplice. Segni diversi possono avere lo stesso significato. La stessa funzione, dunque, è collegata a strutture diverse.

Lo stesso segno può, viceversa, avere usi e significati differenti. Si prenda ad esempio il segno "è". Nell'enunciato "la rosa è rossa" l'"è" ha un significato diverso da quello in "due volte due è quattro". In quest'ultimo caso il segno "è" si può sostituire con il segno d'uguaglianza. Non ha senso, invece, questa sostituzione nel primo enunciato. Lo stesso segno può avere, quindi, significati diversi. La stessa struttura con funzioni diverse.

Da questo non si deduce che non vi sia relazione tra struttura e funzione. Dalla funzione o uso di una proposizione dipende se questa stessa proposizione abbia un senso o meno. Una proposizione è determinata, da un lato, dalle regole di formazione (vedi grammatica della lingua italiana), dall'altro dall'uso dei segni nella proposizione. Ad esempio: comprendere il senso dell'espressione "dare scacco" significa sapere qual è l'uso di quest'espressione nel gioco degli scacchi. Senza il riferimento al ruolo del re nel gioco degli scacchi l'espressione "dare scacco" potrebbe essere priva di significato.

Vi sono funzioni essenziali?

Basta fare anche qui degli esempi per rispondere. È essenziale per la lampada illuminare; non è essenziale che adorni la stanza. Una lampada che non avesse in sé la capacità di illuminare non sarebbe in realtà una lampada. Si direbbe che è inutile, come tutti gli oggetti che hanno una struttura ma non una funzione. Per questo motivo la capacità di illuminare è una funzione essenziale della lampada.

L'individuazione di funzioni essenziali conferma allora la tesi che la funzione è essenziale. Il problema è definire ciò che è essenziale per distinguerlo da ciò che invece non lo è.

Come facciamo a riconoscere ciò che è essenziale?

Si pensi ad un gioco. Il problema di definire ciò che è essenziale nel gioco è, soprattutto, quello di definire il gioco stesso.

Si può, allora, sapere un gioco?

Sembra che vi sia una doppia impossibilità nell'acquisire la conoscenza di un gioco. È impossibile conoscere un gioco, poiché è impossibile conoscere tutte le sue regole. È sempre pensabile l'aggiunta e la sostituzione di nuove regole nel gioco. Il gioco è, tuttavia, anche le regole che apparterranno forse al gioco in futuro. Il gioco è anche le regole che attualmente non sono. Ammesso di avere qui davanti tutte le regole possibili di un gioco,è certo che esse non siano sufficienti a catturare l'intero fenomeno del gioco. Non tutte le azioni che accadono nel gioco hanno, infatti, una regola. Ad esempio: non si sa nulla di quanto in alto e con quanta forza vada lanciata la palla da tennis. Tali azioni caratterizzano, tuttavia, il gioco stesso. Situazioni rilevanti del gioco non hanno una regola, e ciò impedisce di conoscere il gioco fino in fondo.

In realtà noi abbiamo un'idea chiara dei giochi che giochiamo. So bene, ad esempio, che cos'è il gioco del tennis. Avere un concetto di qualche cosa non significa conoscere i singoli individui compresi da quel concetto.

Ad esempio: avere un concetto di cavallo non implica conoscere tutti i singoli individui cavalli.

La stessa cosa vale per l'idea di un gioco. Spiegare un gioco non vuole dire conoscere tutte le regole possibili del gioco, né comporta conoscere tutte le azioni possibili del gioco.

Struttura e funzione non sono, pertanto, la stessa cosa, e non sono della stessa specie le condizioni di validità di un atto.

Condizioni di struttura

La condizione per cui la promessa non può essere se non promessa di cosa futura e non di cosa passata è una condizione di validità strutturale, una condizione cioè relativa alla struttura della promessa. La promessa è un'obbligazione. Ora, un'obbligazione non può essere se non di cosa futura e non di cosa passata.

Le condizione di validità relative alla struttura presuppongono un giudizio analitico in senso kantiano. Sono giudizi analitici i seguenti: "ogni corpo è esteso"; "tutti gli scapoli sono celibi". In questi giudizi il predicato ripete semplicemente ciò che è contenuto nell'idea del soggetto. Ad esempio: se si pensa ad un corpo si pensa sempre ad una *res extensa*. Se si pensa ad uno scapolo si pensa sempre ad uno non ammogliato, cioè ad un celibe. Si tratta di giudizi universali e necessari, giudizi la cui negazione è sempre falsa.

Condizioni di funzione

Il dovere di mantenere le promesse è una condizione di validità funzionale della promessa. Questo dovere è uno dei "doveri perfetti" esemplificati da Kant nella dottrina degli imperativi categorici.

Di seguito viene riportato un passo della metafisica dei costumi (scienza dei doveri morali universali) di Kant:

assumere come legge universale che ogni uomo, quando creda di essere in bisogno, possa promettere qualsiasi cosa col proposito di non mantenere, renderebbe impossibile il promettere stesso e il fine che promettendo ci si propone.

La domanda è se questa massima possa diventare una legge universale. La risposta di Kant è no.

Il punto, però, è un altro. Può una tale condizione (promettere senza un obbligo di adempimento) assurgere a legge universale? La risposta è negativa. Non sarebbe più possibile il promettere stesso, e questo proprio perché verrebbe meno una sua funzione. Nessuno, infatti, crederebbe mai ad una promessa.

Se prometto e l'altro vede subito che sto mentendo, si può chiamare promessa quella che ho fatto? Credo proprio di no. La stessa cosa accadrebbe nel caso di una legge universale che riconoscesse in sé la possibilità di promettere col proposito di non mantenere. Non vi sarebbero mai promesse.

Il valore giuridico dell'adempimento è una condizione generale di validità funzionale degli atti giuridici. Si è detto prima del negozio giuridico. Sono condizioni di validità funzionale di un atto negoziale quelle legate all'effetto o al valore giuridico dell'adempimento. Si pensi al pagamento del

prezzo e alla consegna della cosa, in caso di contratto di compravendita. Senza l'obbligo di pagare il prezzo e di consegnare la cosa non nasce un vero atto di compravendita.

Lo studio delle condizioni di validità funzionale è utile per la logica della costruzione giuridica. Attraverso tali condizioni è possibile individuare dei doveri giuridici necessari, doveri per forza presenti in un ordinamento giuridico ben formato.

Non si può vedere un ordinamento giuridico che tenga debitamente fuori una norma importante sugli atti negoziali. Se è necessario per il diritto in generale il negozio giuridico, sono necessari quei doveri che risalgono sia alla struttura, sia alla funzione essenziale.

Un'obiezione potrebbe muoversi dal **negozio simulato**. In questo caso si intraprende un accordo tra le parti inteso a far apparire ciò che non è, e ad impedire gli effetti essenziali del negozio. Vi sono, pertanto, gli elementi essenziali della struttura del contratto (si è detto, in caso di compravendita: le parti, il consenso, l'oggetto), ma è negata la funzione essenziale (sempre per la compravendita: il pagamento del prezzo e la consegna della cosa come soddisfacimento di un interesse).

Di qui la domanda: è il negozio simulato un negozio valido? Può esistere un atto negoziale che escluda gli obblighi riguardanti gli effetti essenziali?

Se il negozio simulato non è nullo è perché il codice non lo ritiene affatto apparente, almeno rispetto ai terzi in buona fede. "La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente". La creazione di un negozio non vincolante tra le parti è un'attività diversa da quella negoziale.

Le norme che prescrivono gli effetti giuridici tipici del fatto negoziale sono norme giuridicamente necessarie. Si tratta di condizioni dettate dalla "causa" del negozio. L'esclusione degli effetti impedisce di trattare il negozio come un **bene giuridico**. La funzione, infatti, concorre a formare il bene di qualche cosa.

La funzione di un atto stabilisce una vera relazione eidetica con la struttura. Se viene meno la struttura, viene meno anche la funzione dell'atto; se viene meno la funzione, viene meno pure la struttura dell'atto. Struttura e funzione sono, disgiuntamente, condizioni necessarie ma non sufficienti d'esistenza di un atto; solo congiuntamente struttura e funzione sono condizioni necessarie e sufficienti d'esistenza di un atto.

Quale relazione v'è tra regole di funzione e giudizi di verità?

Condizioni che risalgono alla funzione essenziale di un atto appaiono generati da giudizi in cui la relazione tra soggetto e predicato è la stessa di quella dei "**giudizi sintetici a priori**" kantiani.

Condizioni di validità pragmatica, in base alla funzione essenziale di un atto, presuppongono un giudizio sintetico a priori. Il giudizio "l'obbligazione del promittente è il medio della fiducia del promissario" è un giudizio sintetico a priori. È il giudizio da cui si determina quella condizione di validità che è il dovere di mantenere le promesse (la promessa nasce di pari passo con la fiducia del promissario). Si tratta, come si è già detto, di un giudizio sintetico: mette in relazione il concetto di obbligazione(del promittente) con quello diverso di fiducia (del promissario). Il concetto di

obbligazione esprime l'idea strutturale della promessa; quello di fiducia del promissario individua una funzione specifica della promessa. La relazione tra obbligazione del promittente e fiducia del promissario è una relazione necessaria o eidetica.

Ci si domanda se le condizioni a priori di validità siano necessarie alla validità giuridica. Un esempio riguarda proprio la promessa. Si fa il caso della promessa di un soggetto minore d'età per il codice civile del Reich germanico. Chi ha vent'anni è in grado di per sé di fare promesse d'ogni genere; eppure, questo non vale sempre dal punto di vista giuridico. È senza dubbio un presupposto necessario di validità della promessa che a compierla sia un soggetto con la capacità di obbligarsi.

E l'età del promittente? Dall'idea della promessa non si deduce che essa possa essere fatta ad un'età piuttosto che ad un'altra, bensì che il promittente abbia la capacità di obbligarsi. Solo questo si deduce. Il legislatore vuole, in altri termini, assicurarsi che vi sia sempre la capacità del soggetto, allorché questi si voglia obbligare con delle promesse. Per questo è fissata un'età in grado sufficientemente di assicurare la capacità del soggetto promittente. Non si nega una legge essenziale; il principio è, al contrario, quello di dare forza oggettiva ad una legge essenziale.

La norma secondo cui le promesse possano essere fatte da coloro che abbiano compiuto i ventuno anni serve ad assicurare l'oggettività dei rapporti tra il promittente e il promissario: il promissario può essere certo della capacità in sé del promittente di obbligarsi, e non dubitare della promessa. Una cosa è la promessa grazie alla quale si assume un'obbligazione simpliciter (promessa informale) un'altra è la promessa da cui nasce un'obbligazione giuridico-positiva (promessa giuridica).

Infine, va riproposto di nuovo il senso della contraddizione tra essere e dover essere, tra disposizioni del diritto positivo, che implicano un dover essere, e leggi essenziali che risalgono invece all'essere di un atto. Per Reinach ciò non è possibile perché contraddittorio. Ciò che chiamiamo essere (quello indicato dalle leggi essenziali) è, soprattutto, un dover essere. In questo caso l'opposizione sarebbe sempre tra termini omogenei, non più tra essere e dover essere, ma tra un dover essere e la sua negazione. Una legge sarebbe una legge e la sua negazione.

Non si può pensare una promessa, negando che sia un modo di sottomettersi ad un'obbligazione, o che presupponga la fiducia del promissario. Negando questo si negherebbe la stessa promessa. Ciò che la promessa è significa qui, ciò che deve essere. Di ogni cosa che è, perché è necessario che sia, non vi può essere in alcun modo negazione. Rispetto alla proposizione "due più due è uguale a quattro" sono contraddittorie sia la proposizione "due più due non è uguale a quattro", sia la proposizione "due più due non deve essere uguale a quattro".

La deviazione da parte del legislatore dalle leggi a priori di un atto corrisponde ad una deviazione della realtà stessa. Neppure un legislatore divino avrebbe il potere di deviare in questo modo dalla realtà, cioè assumendo la facoltà di porre in essere ciò che non è possibile perché contraddittorio. Qualcosa è possibile in assoluto se il predicato non contraddice il soggetto; viceversa, se il predicato contraddice il soggetto, siamo di fronte a qualcosa che è impossibile in assoluto, come, ad esempio, l'essere un asino per l'uomo.

Oltre la validità pragmatica prima o praxeologica che, risale all'idea stessa di un atto, v'è la validità pragmatica seconda o praxeonomica. Secondo quest'ultimo concetto di validità, vi sono condizioni

che risalgono non più all'idea (*eidos*) dell'atto, ma a norme (*nomoi*) esterne a tale idea. Mentre le condizioni di validità praxeologica esprimono doveri universali e necessari, il secondo tipo di condizioni esprime invece doveri solo possibili: doveri che dipendono da norme solo possibili. Si prenda l'art. 32 del Codice Penale prima della riforma del 1981 sulla perdita della capacità di testare da parte del condannato all'ergastolo. Quest'articolo del Codice Penale pone una condizione di validità dell'atto testamentario, escludendo dai testamenti validi un testamento fatto da un condannato all'ergastolo. È una condizione che non risale all'idea stessa di testamento. Tale condizione risale se mai ad una norma che, ab extra rispetto all'idea dell'atto testamentario, pone una condizione di validità. Si tratta di una condizione che stabilisce una funzione particolare del testamento e della sua eventuale impossibilità: la funzione di pena accessoria. L'impossibilità di fare testamento. L'impossibilità di fare testamento da parte del condannato all'ergastolo ha il senso di pena accessoria. Così come l'art.32 è una norma solo possibile non necessaria, allo stesso modo la funzione di pena accessoria associata al testamento, è una funzione non essenziale del testamento.

La validità praxeonomica è la validità che si predica degli "*accidentalia contractus*", ossia degli elementi del contratto che non preesistono alla volontà delle parti, ma che dipendono esclusivamente da tale volontà: sia per il loro ingresso nella forma del contratto, sia per la loro esclusione. Il venir meno, o il non sorgere affatto di questi elementi non impedisce al contratto di essere tale, né trasforma il contratto nelle figure corrispondenti dell'irregolarità contrattuale.

Condizioni che risalgono alla funzione inessenziale di un atto richiamano dei "giudizi sintetici a posteriori" kantiani. È un giudizio sintetico a posteriori il seguente: "la camicia di Ernesto è nera". La verità di questo giudizio è una verità solo possibile e non necessaria. Per un giudizio come "la camicia di Ernesto è nera" occorre sempre l'esperienza empirica dell'evento nominato; solo grazie all'esperienza è possibile formulare, a ragion veduta, questo giudizio (di qui il suo carattere a posteriori). È infine un giudizio sintetico: nel predicato non si dice quel che è contenuto nella definizione del soggetto. L'idea di camicia non decide di per sé l'essere di colore nero: una camicia può anche non essere di colore nero ma essere di mille colori.

Una questione particolare la pongono quelle condizioni che risalgono alla struttura inessenziale di un atto. La struttura poniamo del testamento olografo (quella di un testamento scritto di proprio pugno dal testatore) non è una struttura essenziale del testamento in sé. Il testamento olografo è un tipo di testamento che non deriva di per sé dall'idea stessa di testamento. Vi possono essere sicuramente ordinamenti che non prevedano, tra le possibili diverse disposizioni testamentarie quella olografa. La condizione però che il testamento olografo sia sottoscritto di mano dal testatore, è una condizione necessaria almeno rispetto all'idea del testamento olografo. Non è pensabile un testamento olografo senza questa condizione. Non è dunque necessario il testamento olografo; è necessaria invece la condizione che esso debba essere sottoscritto di mano dal testatore. Che tipo di condizione è questa??? È in sé una condizione possibile di validità, poiché dipende dall'esistenza di una norma particolare (l'art.602 del Codice Civile italiano); una condizione di questo tipo sembra presupporre la relazione tra soggetto e predicato di un giudizio che non compare nella dottrina kantiana dei giudizi: un giudizio analitico a posteriori. Il giudizio "il testamento olografo è un testamento scritto per intero di mano dal testatore": esprime una verità si analitica ma a posteriori. È un giudizio la cui verità è necessaria poiché nel predicato non si dice nulla di più di quanto è già nell'idea del soggetto; un giudizio tuttavia il cui soggetto è frutto di una produzione a posteriori da

un’idea prima o originaria. In realtà il complesso dei rapporti giuridici tipicamente previsti dall’ordinamento sembrano generati da verità analitiche a posteriori.

6.DOVERI SINTATTICI

Charles W. Morris chiama sintattica la parte della semiotica che studia i rapporti tra i segni. Si tratta dei rapporti che stanno alla base del significato dei segni. La logica della validità sintattica tratta quei segni che sono le norme allo stesso modo. Essa studia l’esistenza delle norme in rapporto ad altre norme, o delle norme in un ordinamento. Così come v’è l’albero v’è anche la foresta; allo stesso modo non v’è solo la norma ma anche l’ordinamento. La validità sintattica implica l’idea che le norme giuridiche non stiano da sole ma si trovino in relazione tra loro e che quest’ordine sia un ordine necessario come è necessario il fatto che vi siano norme.

La teoria della validità sintattica affronta il diritto come ordinamento. In questo senso il problema della validità delle norme si inquadra in quello dell’organismo più complesso che mette insieme appunto le norme in un ordinamento. La validità sintattica non solo presuppone la relazione generica delle norme tra loro, ma identifica pure il nesso secondo cui le una non esisterebbero senza le altre. Una norma esiste a partire da altre norme, da quelle norme che contengono i criteri di validità delle prime. È questo tra l’altro il significato di validità formale nella dottrina pura del diritto di Kelsen. La validità è l’esistenza specifica di una norma. Una norma non ha esistenza da sola. Essa esiste in virtù della sua relazione con altre norme e più direttamente con la norma fondamentale dell’ordinamento al quale appartiene. Vi sono norme che più di altre hanno un posto rilevante nella logica della validità sintattica. Queste norme sono quelle che sono denominate norme di struttura: le norme che fissano le condizioni di validità delle altre norme. La ragione di questa preferenza è duplice: le norme di struttura hanno un chiaro significato ordinamentale, poiché sono norme su norme, fissando le condizioni di esistenza di altre norme. L’esistenza di norme su norme impedisce di pensare le prime senza le seconde e viceversa. L’altra ragione sta nel primato logico delle norme di struttura. Dalle norme di struttura deriva la validità delle restanti norme dell’ordinamento. chiedersi quale sia la validità di una norma vuol dire conoscere quali siano le condizioni di validità che risalgono alle norme sulla validità delle altre norme dell’ordinamento. la validità sintattica è pertanto validità ordinamentale.

Nell’insieme di quelle che chiamiamo norme di struttura ha luogo una differenza: si tratta della differenza tra norme che sono il risultato di atti di produzione e norme che sono semmai non poste ma presupposte. Queste ultime più che norme su norme sono regole su norme o regole su regole e quindi, **metaregole**. Dalle prime scaturisce una validità sintattica seconda o sintasseonomica, validità che risale a norme poste dal legislatore; dalle seconde scaturisce una validità sintattica prima o sintasseologica, validità che risale a norme non poste ma presupposte.

Le norme secondarie sono, norme non necessarie e soltanto possibili: stanno in un ordinamento, ma potrebbero pure non esserci. Sono, invece, meta regole dell’ordinamento tutti quei doveri che stanno come doveri necessari della costruzione giuridica. La validità sintattica si può anche chiamare validità sintasseologica, giacché dipende, più che da norme estrinseche, da principi necessari *ab intra* rispetto all’idea di ordinamento.

È una metaregola dell’ordinamento la norma di chiusura che stabilisce: “nessun’altra norma è valida; valide sono tutte e solo le norme le quali siano o validate secondo regole di formazione, o

validabili secondo regole di trasformazione dello stesso ordinamento. L'insieme delle norme valide è chiuso". La norma di chiusura dispone che se l'ordinamento è l'insieme delle norme valide, e la validità è l'esistenza specifica di una norma in un ordinamento, allora sono norme solo quelle che stanno in un ordinamento. È necessità logica quella per cui un ordinamento è un sistema chiuso. Se vi fossero norme valide fuori dall'ordinamento, ne conseguirebbe o che l'ordinamento non sarebbe l'ordinamento (l'insieme delle norme valide), oppure che le norme valide, dichiarate fuori dell'ordinamento, non sarebbero realmente tali: fuori dall'ordinamento non v'è validità, e una norma non valida non è una norma.

Un altro esempio di metaregola è la kelseniana norma fondamentale. Una norma per esistere ha bisogno di un atto di produzione. Quest'atto non è un atto naturale qualsiasi ma è un atto giuridico. Una prima conseguenza è che la norma prodotta non è sullo stesso piano di quella che produce. La norma che produce è di grado superiore rispetto a quella prodotta. La prima può stare senza la seconda, ma non viceversa. È per questo motivo che l'ordinamento ha, come afferma Kelsen, una struttura a gradi. Accade però un'altra conseguenza importante. Il passaggio dalla norma prodotta (norma di grado inferiore) alla rispettiva norma di produzione (norma di grado superiore) non avviene, né può avvenire, secondo un regresso all'infinito. Ecco perché esiste una norma apicale, al vertice dell'ordinamento, una norma non posta ma presupposta, una norma la cui validità non dipende da una norma di grado superiore. Questa norma è la norma fondamentale. Se v'è l'ordinamento, v'è anche la norma fondamentale di questo ordinamento. Una norma non valida non è una norma. Pensare ad una norma comporta sempre pensare ad una norma in un ordinamento. una norma, infatti, per esistere oggettivamente, ha bisogno almeno della condizione secondo la quale ci si deve comportare secondo le norme effettivamente statuite ed efficaci. Vi deve essere cioè la norma fondamentale.

In che senso la norma fondamentale è una metaregola???

Il senso è questo: la norma fondamentale è valida per l'oggettività di ciò che dice. Ecco qui la sua oggettività: è dall'idea stessa di ordinamento l'obbligo di obbedire ad esso. Un ordinamento che non comprendesse la regola di obbedienza ad esso non sarebbe realmente un ordinamento a causa della stessa contraddizione.

Sia la norma di chiusura, sia la kelseniana norma fondamentale, sono condizioni di validità strutturale. È interessante chiedersi se vi siano anche qui principi che risalgano all'idea di funzione così come si è visto nella validità pragmatica. Senza le regole di funzione non vi è, in generale, un fatto giuridico. Grazie infatti alle regole di funzione, la validità normativa acquista ovviamente un nuovo significato e si riconosce che gli ordinamenti sono molti e non uno solo.

Norberto Bobbio mostra la differenza tra Hart e Kelsen a proposito dell'ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico si può comprendere, secondo Hart, individuandone sia la struttura, sia la funzione: la struttura è quella di un insieme di norme; la funzione sta nelle disposizioni di certezza, mobilità ed efficacia di tale insieme. In Kelsen l'idea è più ristretta. L'ordinamento giuridico è preso solamente per la sua struttura, ed è indicato come un "meccanismo coattivo", ossia come norma.

È significativo un argomento del diritto penale canonico. L'inesigibilità di un comportamento è un criterio tipico del diritto penale canonico. Questo criterio funge da norma fondamentale

dell'ordinamento giuridico della Chiesa, ed è una condizione necessaria di validità normativa che risale alla funzione essenziale di tale ordinamento. l'inesigibilità è un principio conforme alla funzione di quel diritto che ha come legge suprema la salvezza delle anime. Il canone 1752 del codice di diritto canonico recita così: "la salvezza delle anime […] deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema". La legge canonica opera, per la salvezza: questa è la sua funzione, e da qui deriva un limite alla maestà della legge. La conservazione della salvezza richiede di mettere in secondo piano l'efficacia della legge. Si può compiere un'azione contraria alla legge e ricevere lo stesso il perdono, basta che vi sia la retta coscienza. Quel che conta per la salvezza è la retta coscienza e non l'azione esteriore.

Il principio d'inesigibilità non è, invece, un criterio valido del diritto statuale. Lo si riconosce per una serie di ragioni. L'esigibilità è una regola così cogente per il diritto statuale che scavalca i limiti normali della responsabilità personale. L'inesigibilità è circoscritta a ben determinate situazioni all'interno del nostro Codice Penale; in particolare: il caso fortuito, la forza maggiore, lo stato di necessità. Quindi diventa inservibile come categoria generale che possa condizionare l'imputazione e,quindi, la responsabilità. Il principio generale di responsabilità delle persone giuridiche è di origine germanica e ha dominato per tutto il Medioevo. Lo stesso principio lo ritroviamo oggi, ad esempio, nella responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, compresa quella delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica.

Un tema differente da quello della non esigibilità, ma apparentemente simile, è presente nel racconto di "Alice nel paese delle meraviglie". Alice si mostra ostinatamente indifferente ai comandi della regina di cuori. L'esigibilità, come pure l'inesigibilità di un comportamento conforme ad un ordine, suppone sempre la validità di quest'ultimo, e Alice non può essere destinataria di un ordine come se appartenesse alle figure di un mazzo di carte. Lei non appartiene al mondo delle carte, e perciò non sono validi (almeno per lei) gli ordini della regina di cuori.

La norma fondamentale di Kelsen, ad esempio, presuppone che il diritto sia strutturalmente un insieme di norme e basta. Non dice nulla della funzione. La funzione resta un nocciolo decisivo della validità ordina mentale, al punto da fondare il senso di una norma fondamentale diversa da quella di Kelsen. Si vedrà in seguito come ad avere il senso di questa nuova norma sia la "formula trascendentale del diritto pubblico" di Kant nella Pace perpetua.

La validità sintattica seconda è la validità che risale ultimamente a quel tipo di norme di struttura che chiamo, in senso stretto, "norme secondarie". Si tratta di norme solo possibili e non necessarie, norme che sono il prodotto di atti di normazione giuridica. Norme poste e non presupposte sono norme che non sono in sé necessarie ma esistono in virtù di possibili atti di normazione da parte del legislatore. Il più volte citato art.70 della Costituzione: "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere". Essa stabilisce una condizione in sé non necessaria di esistenza delle norme di un ordinamento. Non è detto che la funzione legislativa debba essere esercitata per forza in questa maniera.

A questo genere di norme appartengono pure le norme cosiddette "iterate". A differenza delle altre norme secondarie, le norme iterate partono proprio dal contenuto. Per fare qualche esempio, si pensi a norme che proibiscono di comandare, come la norma che non ammette la pena di morte oppure a quelle che, al contrario, comandano di proibire, come la norma che vieta le associazioni segrete.

Queste norme dicono che non sarebbero valide eventuali norme che istituissero in Italia la pena di morte, o che rendessero lecite le associazioni segrete. Sono norme, come si vede, che stabiliscono la validità di altre norme a partire dal contenuto di quest'ultime e non dalla forma. Ha sicuramente lo schema di una norma iterata la frase notissima apparsa nello slogan sui muri della Sorbonne a Parigi durante la rivolta studentesca del '68: "è vietato vietare". Un caso particolare di norme secondarie, alla base della validità sintasseonomica, è quello delle leggi sulla revisione della Costituzione. Tali leggi si elevano al primato dell'autorità e del potere costituente dal quale sono state pure prodotte, divenendo la norma fondamentale dell'ordinamento giuridico [basic norm] stabilite da un potere costituente. La norma sulla leggi di revisione costituzionale è gerarchicamente superiore alla Costituzione stessa, ponendosi al grado più alto della costruzione dell'ordinamento giuridico, ed è per questo che si potrebbe indicare come norma fondamentale dello stesso ordinamento; tuttavia, essa è anche parte della Costituzione e si colloca perciò allo stesso livello del linguaggio della Costituzione: essa è sempre una norma posta e non presupposta.

7.NORMA FONDAMENTALE

Accertato che la norma fondamentale (Grundnorm) esista e sia valida, dove si fonda la sua validità?

"Esiste la norma fondamentale". Dire questo non basta, tuttavia, a spiegare su che cosa si basi la sua esistenza. Si sa solo che essa, in un modo o nell'altro, esiste realmente. È un procedimento giuridico di tipo sillogistico quello che ci fa accertare la validità di norme in un ordinamento. Per riconoscere la validità delle norme si parte da una premessa che contiene la norma di grado superiore e si giunge, in funzione della conclusione, all'affermazione della validità della norma successiva (prima prodotta grazie alla norma di grado superiore). Lo stesso procedimento si segue per la validità della norma di grado superiore. Ora, se si regredisce di norma in norma, come di premessa in premessa, si giunge ad una norma (la norma fondamentale) che, a differenza delle altre norme dell'ordinamento, determina le condizioni particolari di accertamento della validità:

1) l'impossibilità a figurare, senza contraddizione, a conclusione del sillogismo di accertamento della validità;
2) la necessità di essere affermata come premessa maggiore al vertice del sillogismo che riscontra la validità delle altre norme;
3) l'oggettività presupposta e non posta della sua validità.

In questo modo si sa che v'è una norma fondamentale, ma non si sa su che cosa si fondi la sua validità. Individueremo nel criterio di effettività e in quello di teoreticità due idee sulla validità della norma fondamentale. L'esito non sarà solo quello di rispondere al problema della validità della norma fondamentale, ma anche di introdurre un nuovo significato di questa norma.

Il punto di partenza è un argomento paradossale sulla validità della norma fondamentale. La norma fondamentale non è né valida né invalida. La norma fondamentale, poiché implica tutti gli elementi di quella collezione che è l'insieme delle norme di cui si predica la validità, non è a sua volta un elemento della stessa collezione, ossia una norma di cui è predicabile la validità. Non si potrebbe dire della norma fondamentale che sia valida o meno, proprio perché non v'è un'altra norma grazie alla quale stabilire il senso della sua validità.

La norma fondamentale ha esistenza simpliciter, rispetto ad ogni ordine di validità nell'ordinamento (essa non è valida in virtù di una norma di grado superiore, poiché è appunto la norma che sta al vertice dell'ordinamento); tuttavia, essa ha esistenza secundum quid (è sottoposta ad una condizione precisa di riconoscibilità) circa il fatto che è ciò che è, e non altro. La sua validità è proprio quest'esistenza secundum quid. Per il metro campione non v'è un metro per dire che esso misura un metro; v'è, però, lo stesso una condizione perché valga come metro campione e non come un'altra cosa. La validità della norma fondamentale è, in ultima analisi, la sua esistenza secundum quid. Certo non si può predicare la validità della norma fondamentale così come si predica per le altre norme dell'ordinamento. Occorre cercare altri modi. A quali condizioni, allora, essa esiste specificamente come norma fondamentale? Vi sono almeno due criteri fondanti: il criterio di effettività e quello di teoreticità della norma fondamentale.

Effettività della norma fondamentale

Per la norma fondamentale di un particolare ordinamento è essenziale l'effettivo comportamento di quegli uomini ai quali si riferisce l'ordinamento stesso. Il problema non è quello dell'accertamento di quale fatto debba accadere per stabilire la validità o meno di una determinata norma fondamentale, ma di riconoscere che è essenziale per la norma fondamentale l'esistenza di un fatto ("l'effettivo comportamento di quegli uomini ai quali si riferisce l'ordinamento giuridico"). In conclusione, anche della norma fondamentale si può dire che è valida o invalida; la validità della norma fondamentale è il prodotto di un fatto e di un fatto particolare: l'effettivo comportamento dei destinatari di tale norma, o dell'ordinamento di cui tale norma è appunto la norma fondamentale.

Teoreticità della norma fondamentale

La norma fondamentale è valida per l'oggettività di ciò che dice. Lo schema logico della norma fondamentale non prescrive che si deve obbedire a questo o a quest'altro ordinamento, ma che "ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace", qualunque sia questa Costituzione o questo ordinamento. Un ordinamento comanda sempre il proprio adempimento. Un ordinamento che non comprendesse la norma di obbedienza ad esso non sarebbe realmente un ordinamento a causa della stessa contraddizione. Allo stesso significato oggettivo si rifà, tra l'altro, la norma di chiusura dell'ordinamento: "Nessun'altra norma è valida; valide sono tutte e solo le norme le quali siano, o validate secondo regole di formazione dell'ordinamento, o validabili secondo regole di trasformazione dello stesso ordinamento. L'insieme delle norme valide è chiuso". Non vi sono norme al di fuori di quelle dell'ordinamento (l'ordinamento è la totalità della norme vigenti). Dire il contrario equivale ad affermare che l'ordinamento non è l'ordinamento. Due sono le possibilità: l'ordinamento è davvero tale, e perciò non vi sono norme fuori dell'ordinamento, oppure le norme fuori dell'ordinamento non sono norme valide, o più semplicemente non sono norme. In ultima analisi, anche della norma fondamentale si può predicare la validità. La validità della norma fondamentale è il significato necessario di una proposizione logica. La sua invalidità è il frutto di una contraddizione logica.

Le due soluzioni (effettività e teoreticità della norma fondamentale), prese congiuntamente e non separate tra loro, sembrano tracciare un ulteriore paradosso: secondo l'effettività, la validità è il prodotto di un fatto e di un fatto particolare o soltanto possibile; secondo, invece, il criterio di teoreticità, la validità è il significato necessario di una proposizione logica. Da un lato v'è

semplicemente un fatto, dall'altro un'idea logica; da un lato il principio è particolare e contingente, dall'altro è universale e necessario. Si può affermare che la validità della norma fondamentale sia nell'insieme possibile e necessaria, senza contraddizione? È una contraddizione affermare che la validità della norma fondamentale sia nello stesso tempo, e secondo il medesimo rispetto, necessaria e soltanto possibile. Effettività e teoreticità della norma fondamentale determinano, dunque, insieme due soluzioni opposte tra loro? No. È vero che la validità della norma fondamentale presenta predicati di cui l'uno è la negazione dell'altro, ma rispetto a differenti significati della stessa norma fondamentale. In altri termini, cambiano i predicati, ma cambia pure il soggetto; i predicati non sono predicati dello stesso soggetto. La validità della norma fondamentale è, nello stesso tempo, necessaria e non necessaria (solo possibile), ma non secondo il medesimo rispetto. Vi sono, infatti, almeno due significati della norma fondamentale.

Il primo di questi significati è quello che risale alla norma fondamentale di un ordinamento giuridico particolare (quest'ordinamento potrebbe essere, ad esempio, l'ordinamento italiano):

"Ci si deve comportare secondo R – la Costituzione effettivamente statuita ed efficace", dove "R" sta per la Costituzione di un ordinamento giuridico italiano;

Il secondo significato introduce, invece, la norma fondamentale come schema o forma logico-giuridica che condiziona la validità di ogni ordinamento giuridico: "ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace." Questa norma è valida in sé necessariamente, poiché discende dall'idea stessa di ordinamento giuridico. Essa è valida per l'oggettività di ciò che dice: è dall'idea stessa di ordinamento che nasce l'obbligo di obbedire ad esso.

L'effettività è il criterio di validità della norma fondamentale di un determinato ordinamento giuridico. V'è poi, un'idea teoretica: questa è quella della norma fondamentale che condiziona la validità di ogni ordinamento giuridico.

EFFETTIVITÀ = verso il particolare (norma fondamentale di un solo ordinamento).

TEORETICITÀ = verso l'universale (idea alla base di ogni ordinamento).

8.REGOLE ED EIDE

Ad approfondire il significato della norma fondamentale sarà ora la teoria delle "regole costitutive". In particolare, si prenderà in esame il significato della norma fondamentale come regola che più specificamente si designa col sintagma nominale regola "**eidetico-costitutiva**".

Si chiamano regole eidetico-costitutive quelle regole le quali sono condizioni necessarie sia di pensabilità, sia di possibilità di ciò su cui esse vertono. Ad esempio: il gioco degli scacchi non è neppure pensabile senza le sue regole; né tantomeno esso è possibile, se escludiamo le stesse regole. Il gioco non sussiste, quindi, senza le regole che lo compongono.

In che senso, allora, la norma fondamentale è una regola eidetico-costitutiva? Di che cosa essa è condizione di pensabilità e possibilità? Gli oggetti sono almeno due: l'ordinamento giuridico e l'insieme dei fenomeni giuridici in generale. La norma fondamentale è regola eidetico-costitutiva dell'ordinamento giuridico. Se la cosiddetta "norma generale esclusiva" ("norma che qualifica deonticamente indifferente ogni comportamento non qualificato da norme imperative") è

reinterpretata come la norma fondamentale (Grundnorm). La norma generale esclusiva non è più norma tra norme: essa è condizione di possibilità e pensabilità dell'ordinamento come tale. La norma generale esclusiva non è una norma necessaria di ogni ordinamento. La norma generale esclusiva, ad esempio, è eccettuata da tutti quegli ordinamenti che si possono chiamare stato di diritto. Negli ordinamenti, invece, detti stato di diritto, essa non soltanto è una norma necessaria, ma è la norma fondamentale che connota tali ordinamenti: essa, in altre parole, è condizione di pensabilità e possibilità di quegli ordinamenti.

V'è un secondo oggetto su cui verte la norma fondamentale. Rispetto a questo secondo oggetto, la norma fondamentale è regola eidetico-costitutiva dei fenomeni giuridici in generale. Kaufman sostiene che non vi sono fenomeni giuridici precostituiti alla norma fondamentale e percepibili irrelativamente ad essa. Naturalmente non manca un nesso tra questi due oggetti (ordinamento giuridico e insieme dei fenomeni giuridici in generale), proprio perché i fenomeni giuridici dipendono, a loro volta, da una precisa qualificazione normativa. La norma fondamentale è sempre costitutiva di ordinamenti normativi ed, insieme, di fenomeni giuridici più in generale. "Come la Grundnorm è costitutiva rispetto alle singole norme di un ordinamento, così le singole norme dell'ordinamento sono (a loro volta) costitutive rispetto ai fenomeni qualificati dall'ordinamento.

La norma fondamentale ha almeno due significati:

1) come principio di validità di un ordinamento giuridico particolare ("Ci si deve comportare secondo R – la Costituzione effettivamente statuita ed efficace", dove "R" sta per la Costituzione di un ordinamento giuridico particolare);
2) come schema o forma logico-giuridica astratta che condiziona la validità di ogni ordinamento giuridico ("Ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace", qualunque sia questa Costituzione).

È la norma fondamentale una regola eidetico-costitutiva sia nel primo, che nel secondo significato? Che la norma fondamentale, coma causa di validità di un determinato ordinamento, sia regola eidetico-costitutiva non vi sono dubbi. Essa è davvero condizione necessaria sia di pensabilità, sia di possibilità delle norme dell'ordinamento.

Vale la stessa cosa per la norma fondamentale come schema o forma logico-giuridica alla base di ogni ordinamento? Occorre fare prima alcune osservazioni su quelle che sono chiamate **regole costitutive**.

Le regole costitutive sono un fatto possibile, e non l'idea in sé necessaria alla base di una serie di fatti possibili. Le regole, ad esempio, di un gioco, come il gioco degli scacchi, sono solo un fatto possibile e non necessario. Esse costituiscono uno dei giochi possibili, e non l'idea, in sé necessaria, della ludicità, l'idea cioè che tutti quanti gli uomini hanno non di questo o di quel gioco, ma del gioco in sé. L'idea del gioco in sé non dipende dall'esistenza o meno di un gioco particolare, e, dunque, dalle regole costitutive di quest'ultimo. Inoltre, le regole costitutive non esprimono il significato necessario di una proposizione logica. Questa potrebbe essere la proposizione che definisce il gioco in sé. Le regole costitutive traducono, invece, delle implicazioni solo possibili di tale proposizione logica. Le regole del gioco degli scacchi sono un'implicazione possibile della proposizione logica che definisce il gioco in quanto tale: ha senso certo dire che il gioco degli

scacchi sia un gioco, ma non ha senso dire il contrario, quasi che il gioco in sé fosse il gioco degli scacchi e basta.

Le regole eidetico-costitutive non riescono a spiegare l'intero fenomeno della norma fondamentale. La norma fondamentale è, semmai, l'idea che sorregge queste stesse regole.

La norma fondamentale come principio di validità di un ordinamento giuridico particolare esprime il senso di una regola eidetico-costitutiva; la norma fondamentale come schema o forma logico-giuridica astratta esprime, invece, il senso dell'idea (eidos) del diritto come ordinamento. L'una norma (la prima) presuppone l'altra. La norma fondamentale (nomos) dà l'idea dell'ordinamento giuridico (eidos). Il dovere che risale alle regole eidetico-costitutive è il dovere di un nomos che dà forma ad un eidos. Vedi il dovere di quel nomos che sono le regole del gioco degli scacchi, le quali danno forma all'idea (eidos) dello stesso gioco degli scacchi.

Il dovere che risale ad eide, è piuttosto, il dovere di un logos che si ricava da un eidos. A questo tipo di doveri appartengono quelli della validità pragmatica prima o praxeologica, o della validità sintattica prima o sintasseologica.

9.IUS PUBLICUM

La norma fondamentale presa come schema o forma logico-giuridica astratta presuppone che l'ordinamento giuridico abbia un significato essenzialmente normativo: l'ordinamento è fatto di norme o di principi normativi. Partendo dal significato della norma fondamentale, si ha, infatti, la doppia evidenza dell'esistenza dell'ordinamento giuridico (ogni norma ha almeno un'altra norma di grado superiore , vale a dire una norma fondamentale) e dell'identificazione dell'ordinamento giuridico con un nucleo di senso che non può essere che quello normativo. È questa l'idea nodale della dottrina normativistica del diritto. Essa indica nell'elemento della norma la struttura dell'ordinamento giuridico.

Nell'ordinamento v'è una norma fondamentale ma vi sono anche norme di struttura, subordinate a tale norma, che regolano e fissano le condizioni di validità degli atti di decisione giuridica. La struttura, dunque è la norma. E la funzione? V'è una norma fondamentale relativamente non più alla struttura, ma alla funzione dell'ordinamento giuridico in sé?

Per un normativista come Kelsen vi può essere la domanda esclusivamente sulla struttura dell'ordinamento giuridico poiché lui considera solo la struttura della norma fondamentale tralasciando la sua funzione.

Funzione, allora, di che cosa? Esiste pure qui, al pari degli atti giuridici, una funzione essenziale?

L'ordinamento giuridico si può comprendere, secondo Hart, se si ha presente sia la struttura specifica, sia la funzione di esso: la struttura è quella normativa (l'ordinamento è strutturalmente formato da norma), mentre la funzione sta nelle disposizioni di certezza, mobilità ed efficacia del sistema normativo stesso. In Kelsen le cose non stanno così. L'analisi strutturale appare separata da

quella funzionale, con l'esclusione della seconda in favore della prima. Il diritto è preso solamente per la sua struttura, ed è indicato come un "meccanismo coattivo", ossia come norma.

La domanda è anche se vi siano funzioni essenziali, funzioni necessarie e non solo possibili. La funzione appare, infatti, più un elemento variabile che fisso. Uno stesso istituto giuridico, ad esempio, può vivere cambiamenti anche radicali riguardo alla sua funzione sociale. Prendiamo l'istituto della proprietà. Lo sviluppo della società per azioni, ha decretato la separazione fra proprietà e controllo della ricchezza. Chi detiene la ricchezza non l'amministra; chi l'amministra non ne è proprietario. Ora, mutando la funzione sociale della proprietà, muta anche la funzione dell'insieme delle norme che formano l'istituto giuridico della proprietà. La funzione delle norme finisce per essere, in questo modo, un aspetto solo variabile delle norme. V'è un altro fenomeno rilevante. La stessa funzione può generare meccanismi normativi differenti (meccanismi cosiddetti "equifunzionali"). Non cambia la funzione, ma cambiano i mezzi.

È un esempio, invece, di norma fondamentale, secondo la funzione del diritto, la formula "trascendentale del diritto pubblico" che Kant espone nella Pace Perpetua. Stando a questa formula, tutte le azioni che concernono il diritto di altri uomini presuppongono dei doveri che siano compatibili con la forma della pubblicità. Esiste una funzione essenziale dell'ordinamento giuridico individuabile con Hart nell'efficacia dell'ordinamento giuridico stesso, e per questo v'è un dovere giuridico necessario: questo dovere è appunto quello di pubblicizzabilità delle massime giuridiche. Si tratta di una vera e propria norma fondamentale.

La pubblicità ha una generale efficacia costitutiva dei fatti giuridici lato sensu. Essa fa sì che certi fatti siano fatti giuridici sotto vari aspetti, sia per l'esistenza stessa dei fatti, sia per la prova della loro esistenza, sia, infine, per accertare il valore che questi fatti possono avere. Si individuano così almeno tre oggetti possibili della forza costitutiva della pubblicità: fatti, giudizi di fatto, giudizi di valore.

Fatti

Vi sono fatti che per essere fatti giuridici devono avere necessariamente un carattere di pubblicità. La pubblicità è una condizione necessaria di possibilità dei fatti giuridici. Ad esempio, la pubblicazione di una legge fa essere e rende normativamente operante quest'ultima così come la pubblicazione di una sentenza perfeziona la stessa e la rende irretrattabile.

Giudizi di fatto

Vi sono fatti che per essere provati giuridicamente devono possedere necessariamente un carattere di pubblicità. L'iscrizione, ad esempio, dell'atto di nascita ha efficacia probatoria relativamente alla stessa nascita e, dunque, all'acquisto della personalità giuridica. La pubblicità non determina ovviamente il fatto stesso della nascita, bensì la prova che quest'ultima sia avvenuta. In questo senso non è costitutiva del fatto, bensì del giudizio sul fatto: ti fa dire che il fatto è realmente accaduto. Con la pubblicità si forma la certezza dei fatti.

Giudizi di valore

La pubblicità, oltre che costitutiva di fatti e di giudizi di fatto, è pure costitutiva di giudizi di valore, nel senso almeno di cui tratta Kant nella seconda appendice della Pace perpetua.

“Tutte le azioni concernenti il diritto di altri uomini, la massima delle quali non sia compatibile con la pubblicità, sono ingiuste”.

È questa, secondo Kant, una “**formula trascendentale del diritto pubblico**”.

Si tratta di una formula trascendentale, poiché ottenuta sulla base solo di un’idea: non vi può essere legalità senza pubblicità. Una massima o pretesa giuridica che non fosse pubblica, perché incapace di avere la forma della pubblicità, non sarebbe tale. Dicendo che è falsa, Kant intende che una tale massima o pretesa non può nascere realmente.

Il punto di partenza è, allora, che le norme sono valide quando, per così dire, stanno non solo nelle teste dei legislatori, ma si trovano anche presso i destinatari, e che la validità è anche “validità da parte dei destinatari”. Questo significa due cosa: che le norme devono essere pubbliche, ma anche che le norme devono avere la possibilità stessa di essere pubbliche, ossia i destinatari, quando sono a conoscenza di esse, le fanno proprie e non le respingono. Nel fatto che i destinatari non le disconoscano ma le accettino è la prima funzione delle norme.

La pubblicità è insieme il risultato di un processo di astrazione e il principio che svela la funzione delle norme; dice quali norme hanno efficacia e quali no. La pubblicità è, allora, necessaria così com’è necessario che le massime realizzino la loro funzione. Al diritto corrispondono tutte quelle massime che hanno la forma della pubblicità. Questa forma costituisce il medio tra le massime del diritto e la loro funzione. La pubblicità corrisponde ad un principio insieme giuridico ed etico.

La forma della pubblicità è implicita in ogni pretesa che voglia essere davvero giuridica, così com’è implicito in ognuna di tali pretese un carattere necessario di giustizia. Ogni pretesa è giusta se è pubblicizzabile. Le pretese non pubblicizzabili sono ingiuste. Anzi, esse non sono pubblicizzabili proprio in ragione della loro ingiustizia. L’ingiustizia è ciò che rende impossibile la pubblicità, così come impedisce al diritto di essere. Viceversa, “una legge pubblica che determini per tutti cosa sia loro permesso o vietato è l’atto di una volontà pubblica dal quale proviene ogni diritto, e che perciò non può recare ingiustizia a nessuno”.

Kant fa degli esempi. Uno è quello di una massima che sostenga, nei rapporti tra gli Stati, la possibilità da parte di un sovrano di venire meno alla parola data. Si potrebbe mai rendere pubblica questa massima? La risposta è no.

Kant fa ancora due esempi. Non avrebbe una buona riuscita la massima che autorizzasse uno Stato a muovere un attacco ad un altro, la pubblicità renderebbe inattuabile la massima che autorizzasse uno Stato più grande ad assoggettare senza ragione uno Stato minore e ad annetterlo al proprio territorio.

Il primo esempio, sulla lealtà nei patti tra gli Stati, richiama un esempio di **dovere perfetto** che Kant fa nella “Fondazione della metafisica dei costumi”. Si parla di un tale costretto dal bisogno a farsi prestare del denaro. La massima della sua azione prenderebbe questa forma: “Quando credo di non aver bisogno di denaro, ne prendo a prestito promettendo di restituirlo, benché sappia che non lo farò mai”. Che cosa accadrebbe, dunque, se si elevasse una tale massima a legge universale? Sarebbe impossibile il promettere stesso. La stessa massima sarebbe ingiusta. L’universalizzabilità delle massime presenta, infatti, lo schema attraverso cui l’imperativo categorico – imperativo che comanda di agire in modo che la massima della propria volontà possa valere al tempo stesso come

legge universale – esprime l'idea della giustizia. La massime che non sono universalizzabili sono anche ingiuste. La differenza tra i due casi è chiara. Da un lato si intende verificare la pubblicizzabilità di una massima, dall'altro la sua universalizzabilità. La differenza è la stessa tra dottrina del diritto e dottrina della virtù: il dovere morale è interno, mentre quello giuridico è soprattutto esterno. L'agire giuridico è doverosamente esterno e non interno. Quello morale è doverosamente interno e non esterno. Questo spiega perché la pubblicità delle massime sia la forma della legislazione giuridica: la legislazione giuridica è esterna e non interna. La pubblicità delle massime traduce così un tratto specifico della giuridicità: il fatto che le massime giuridiche debbano essere pubbliche deriva semplicemente dalla circostanza che si tratta di massime giuridiche e non di massime morali.

È spiegata così l'origine della pubblicità nel diritto, ma non è spiegato abbastanza il nesso tra pubblicità e giustizia delle massime. Per questo aspetto la pubblicità ha a che fare strettamente con l'universalità. Le massime giuridiche sono pubblicizzabili perché anche universalizzabili; sia l'uno sia l'altro pervengono ad individuare gli stessi doveri.

Mettiamo che la legge sia una legge impossibile come quella di Fuller: "Tutti i membri del Parlamento sono da un momento in poi liberati da ogni limitazione da parte di qualsiasi legge, e sono autorizzati a rubare, uccidere e violentare senza incorrere in sanzioni penali". Considerata come legge universale (legge incondizionatamente valida), questa legge renderebbe impossibile l'idea stessa di ordinamento. le leggi, infatti, potrebbero pure continuare ad essere emanate, ma nessuno vi obbedirebbe. Ora, una legge del genere non è pubblicizzabile nella stessa misura in cui può essere elevata a legge universale. E questo è quanto basta per affermare che è ingiusta.

La cosa interessante è che siamo passati da un principio formale (il principio di pubblicizzabilità e/o di universalizzabilità) ad uno materiale come quello della giustizia. Il fatto che si vada dall'uno all'altro principio in questo modo secondo Kant è una necessità. Non v'è dubbio che la precedenza spetti al principio formale. Solo dal principio formale possono dipendere condizioni di validità necessarie e non soltanto possibili. Si determina la priorità del principio formale su tutti i fini materiali dell'azione.

Non mancano i rischi. Il rischio maggiore è di far retrocedere l'universale vero nella posizione dell'universale falso. L'universale falso è l'universale che difende istanze solo apparentemente universali, ma in realtà particolari. Per tenere sufficientemente conto dell'universale e della sua vera ragione, occorre rispettare maggiormente la precedenza del principio formale. Quanto meno si fa dipendere il diritto da un fine prefissato, tanto più esso si adegua ad un'idea necessaria. Questo non significa l'assenza dei fini, ma che questi siano ben fatti.

Va evidenziata ancora un'altra differenza che serve a chiarire ulteriormente la proposta di universalità dello ius publicum. Molti dei doveri finora riportati sono tali che non è neppure pensabile l'idea di negarli. Si ricordi l'esempio del dovere di mantenere le promesse. Si tratta di doveri che Kant chiama perfetti, doveri che non dipendono dall'inclinazione soggettiva della volontà, ma da una causa esclusivamente interna alla ragione. L'universale, però, è anche di un'altra specie. Qual è, allora, quest'altro universale? Kant individua una forma diversa di universale nei cosiddetti doveri imperfetti. Sono doveri che guadagnano l'universalità a causa non più della

ragione, ma della volontà, giacché mentre è pensabile di essi la negazione, non è certo la stessa negazione desiderabile.

Un esempio: si parla di un tale al quale tutto va bene e che potrebbe benissimo aiutare coloro che si dibattono fra gravi difficoltà. La domanda è se vi sia una legge universale della natura che salvi la massima secondo la quale non si è tenuti a dividere i propri beni con i bisognosi, e, nondimeno, è impossibile volere che tale principio abbia valore universale di legge della natura.

Si potrebbe di per sé elevare questa massima a legge universale di natura? Sì.

Si potrebbe, tuttavia, volere una legge del genere? La risposta questa volta è negativa.

L'universale è almeno di due specie. Esso è fondato in senso o teoretico, o pratico. Negando il primo si ha una contraddizione interna alla ragione, negando il secondo, la contraddizione risulta interna alla volontà. Esistono doveri universali di cui non si può neppure pensare la negazione, ed altri che fondano il loro carattere di universalità sulla volontà. Secondo quest'idea, il contenuto delle leggi è formato da quelle azioni che tutti, o la maggioranza delle persone libere, vorrebbero fossero compiute.

La formula trascendentale del diritto pubblico di Kant ha tutto il senso di una norma fondamentale come schema logico-giuridico astratto. Come la norma fondamentale di Kelsen essa è il presupposto logico di ogni ordinamento giuridico in sé. Non vi può essere legalità senza la forma della pubblicità.

La formula kantiana esprime, pertanto, il senso dell'idea del diritto. Con quale differenza rispetto a Kelsen? Tramite la formula di Kant si afferma semplicemente che il diritto è norma, ma si pone la questione della funzione del diritto. La pubblicità forma, allora, un criterio a priori della ragione, per determinare quali norma sussistono, perché efficaci, e quali no. Il diritto spiegato da questa angolazione non può che essere ius publicum.

Se non fosse possibile rendere pubbliche le norme di un ordinamento, "non vi sarebbe nessuna giustizia (la quale può essere concepita solo come pubblicamente conoscibile), e di conseguenza nessun diritto.

La formula di Kant, proprio perché è principio non solo giuridico ma anche etico, è, propriamente parlando, non una norma fondamentale (Grundnorm), ma un valore fondamentale (Grundwert).

10.LA COSCIENZA INFELICE

Come si comporta la coscienza dinanzi all'universale? L'universale può diventare il negativo della coscienza e costringere la coscienza stessa ad essere "coscienza infelice". Le figure di stoicismo e di scetticismo, descritte da Hegel nella "Fenomenologia dello Spirito", anticipano idealmente questo malessere della coscienza, malessere che si forma dapprima sostenendo l'inutilità del mondo e della vita, e poi togliendo a questi due ultimi un fondamento assoluto.

Lo stoicismo è la coscienza che mira a rendersi libera facendo dipendere tutto dall'interno della coscienza stessa. La coscienza stoica finisce per cadere in una lotta insostenibile con la vita. Si proclama indipendente come coscienza singola, dichiara di essere sufficiente a se stessa, ma presto incontra la resistenza della vita. Quanto più indipendente si dice la coscienza, tanto lo è in sé la vita.

Alla fine si tratta di una libertà solo astratta. In questo modo la coscienza non fa che generare tedio. Ha di fronte a sé la vita e si comporta come se quest'ultima non vi fosse.

Lo scetticismo porta a compimento quest'atteggiamento negativo della coscienza. Lo scetticismo esprime una fuga incessante della coscienza dinanzi a sé. Lo scetticismo pone l'universalità al posto della singolarità, ma facendo questo manifesta un'ambiguità sconcertante nel termine restante. Da qui nasce il malessere. La coscienza scettica vede tutto, compresa se stessa, come qualcosa di mutevole, eppure essa stessa ha come essenza l'immutabile, e quando la coscienza vede che l'immutabile è la sua essenza, non fa che essere la coscienza di qualcosa di mutevole. L'infelicità si produce quando la coscienza si smarrisce nell'opposizione dell'io col non io, in un passaggio senza fine dall'essere al non essere e dal non essere all'essere.

V'è bisogno per la coscienza della riconciliazione tra la sua singolarità e l'universale. Per operare questa riconciliazione, bisogna mettersi dal punto di vista dell'universale e comprendere che mondo e vita sono parte dell'universale. Solo la riconciliazione può orientare la coscienza e darle un po' di pace.

Ringraziamenti:

Questo lavoro è stato interamente prodotto da Francesco Presicci e da Luca Perrone con l'attento studio del libro intitolato "Sul dovere giuridico" di Antonio Incampo, testo utilizzato per il corso di Filosofia del diritto tenuto dal Prof. Antonio Incampo presso l'Università di Bari nella sede distaccata di Taranto.

Si consiglia a chiunque volesse far uso di queste pagine una preventiva lettura attenta del libro.

Quest'opera riassuntiva è disponibile gratuitamente solo presso il sito: www.progettouniversitario.tk ed è vietato qualsiasi uso improprio di essa.